

1500174-37.2021.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... droga, o que só vem reforçar que ali se praticava o tráfico, haja vista que, como é cediço, balanças desse tipo são utilizadas para quantificar as porções que serão vendidas.

Ademais, no laudo de fls. 199/263, especificamente nas fls. 254/258, há diversas conversas pelo whatsapp, relacionadas ao tráfico de drogas, bem como fotografias de entorpecentes e armas de fogo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

1ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500174-37.2021.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500174-37.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2024678/2021 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 15907595 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI,

310/21/309 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 2024678 - DEL.POL.BIRIGUI, 310/21/309 -

DEL.POL.BIRIGUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFERSON SANCHES DE SOUZA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

S E N T E N Ç A

Processo nº 1500174-37.2021.8.26.0603 (Controle 241/2021)

VISTOS.

JEFFERSON SANCHES DE SOUZA E SILVA, qualificado nos autos, foi preso em flagrante

delito, denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 27 de janeiro de 2021, por volta das 10h30min, à Rua Valério Anhê Ribalta, nº 563, Residencial Portal da Pérola II, nesta cidade e Comarca de Birigui, guardava 871,74g (oitocentos e setenta e um gramas e setenta e quatro centigramas) de maconha, substância entorpecente, que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de contatação provisória de fl. 28 e exame toxicológico de fls. 103/105.

Oferecida a denúncia, o réu foi notificado para apresentar defesa escrita (fl. 119), cuja peça foi juntada às fls. 125/126, sobrevivendo o recebimento da denúncia em 04 de maio de 2021 (fls. 179/180) e a citação do acusado à fl. 269.

Na instrução, foram colhidos os depoimentos de 03 (três) testemunhas arroladas em comum e 01 (uma) testemunha arrolada pela defesa, sobrevivendo, ao final, o interrogatório do réu (fls. 304/305).

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado, nos exatos termos da denúncia (fls. 309/313).

A defesa, por sua vez, pediu a absolvição do réu, porque há dúvidas quanto à propriedade da droga. Em caso de condenação, requereu o reconhecimento da confissão e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos (fls. 316/322).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

A ação penal é procedente.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido, temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); o boletim de ocorrência (fls. 23/25); a nota de culpa (fl. 07); o relatório final (fls. 92/93); o laudo de constatação prévia (fl. 28); os laudos periciais (fls. 103/105 e 152/155) os depoimentos das testemunhas; e a confissão apresentada pelo acusado em juízo.

Na delegacia, o acusado disse que discutiu com sua ex-companheira Simone, e ela fez a denúncia aos policiais. Os policiais chegaram e encontraram a maconha em um terreno próximo à casa de Simone. Afirmou que a droga era sua e de Simone, e não sabia onde ela havia guardado (fl. 06).

Em juízo, confessou que guardava cerca de 800 gramas de maconha e uma balança para uma pessoa de Araçatuba, e receberia R\$ 2.000,00 para guardá-las. Disse que mostrou aos policiais que os entorpecentes estavam escondidos em dois terrenos. Afirmou que é usuário de drogas (fls. 304/305).

A confissão livre e espontânea prestada no processo, serve como importante elemento de convicção para evidenciar a autoria e amparar a condenação, quando encontrar sustentação nos demais elementos de convicção produzidos.

De fato, no caso, a confissão do réu encontrou total respaldo nas demais provas carreadas aos autos.

Com efeito, as testemunhas Agnaldo Januário e Marcos Silveira da Silva, policiais militares, ouvidas em ambas as fases da persecução penal, relataram que foram informados pela testemunha Simone, que o namorado dela estava guardando drogas em dois terrenos vizinhos a sua casa. Foram até a residência, indagaram o acusado Jeferson, que confirmou que estava guardando entorpecentes e que havia jogado uma pequena porção de maconha na área verde e escondido o restante em um terreno baldio. Foram até os locais e encontraram três partes de tijolos de maconha e uma pequena balança de precisão. O réu assumiu que era o proprietário dos entorpecentes apreendidos (fls. 03, 04 e 304/305).

Os policiais confirmaram que localizaram quantidade considerável de entorpecentes e

uma balança de precisão, e que o réu confessou que estava guardando os entorpecentes.

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Tais depoimentos somente não terão valor quando se evidenciar o interesse dos servidores na investigação penal, e quando suas declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

Importante salientar que não existe qualquer circunstância que justificasse o interesse dos policiais em prejudicar o acusado, ou em imputar falsamente a ele a prática de conduta definida como crime, sobretudo porque ele não apontou nada que justificasse essa circunstância.

A testemunha Simone Rocha Capellari, ouvida na fase policial e judicial, disse que tem um relacionamento amoroso com o réu há 03 anos. Como ele estava guardando drogas na sua casa, acionou a polícia militar e informou sobre os fatos, ocasião em que Jeferson mostrou aos policiais onde estavam os entorpecentes. Em juízo, acrescentou que viu quando o acusado guardou a droga no terreno baldio, e que Jefeson confirmou que iria vender os entorpecentes (fls. 05 e 304/305).

A testemunha de defesa Lourdes Sanches de Souza, ouvida em juízo, nada soube esclarecer sobre os fatos, limitando-se em tecer comentários sobre o réu (fls. 304/305).

No que se refere aos entorpecentes, a perícia apontou que consiste realmente em "maconha" (exame químico-toxicológico de fls. 103/105).

De outra parte, a quantidade de entorpecente apreendido, ou seja, 871,74 (oitocentos e setenta e um gramas e setenta e quatro centigramas) de maconha, as circunstâncias da abordagem do réu (denúncia de que o réu estaria guardando drogas em sua residência); a apreensão da balança de precisão, e a confissão do réu em juízo, estão a caracterizar a traficância.

No caso, não se pode olvidar que foi apreendida uma balança de precisão juntamente com a droga, o que só vem reforçar que ali se praticava o tráfico, haja vista que, como é cediço, balanças desse tipo são utilizadas para quantificar as porções que serão vendidas.

Ademais, no laudo de fls. 199/263, especificamente nas fls. 254/258, há diversas conversas pelo whatsapp, relacionadas ao tráfico de drogas, bem como fotografias de entorpecentes e armas de fogo (fls. 259/262), o que só vem confirmar a confissão do acusado quanto ao tráfico de drogas.

Nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente guarde a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado. No caso, o réu foi denunciado guardar entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para a venda a terceiros.

Assim, além da robusta prova acima analisada, há indícios mais que suficientes para a prolação de decreto condenatório. Aliás, neste ponto, tratando-se de delito, na maioria das vezes, praticado às escondidas, não se pode abrir mão dos indícios para o estabelecimento da verdade real. E a definição de indício vem estabelecida no próprio Código de Processo Penal, no artigo 239. Com isso, constata-se que o juiz formará a sua convicção na livre apreciação da prova, e, diante do nosso sistema processual, o indício é o fato provado que, por sua ligação íntima com o fato probando, autoriza a concluir algo sobre este, até porque os indícios estão inscritos no título da prova, e, assim, a autoria do delito, pelo sistema do livre convencimento, pode ser demonstrada, validamente, pela força probante dos indícios. Sendo assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local indicados na denúncia, o acusado guardava 871,74 (oitocentos e setenta e um gramas e setenta e quatro centigramas) de maconha, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de entrega a consumo de terceiros.

A conduta do réu encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, exclua a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade. Neste ponto, embora o acusado, em seu interrogatório, tenha alegado que é usuário de drogas, tais alegações não restaram comprovadas, até porque a defesa não juntou quaisquer documentos, não requereu qualquer exame de dependência químico-toxicológico ou de insanidade mental. Ademais, em seu interrogatório, o réu mostrou-se lúcido.

Ressalto que, mesmo que se demonstrasse que o réu fosse usuário de drogas, isso, por si só, não lhe impediria de exercer a traficância. Muito pelo contrário, há grande afinidade entre uma e outra condutas. Se o réu é viciado há um bom tempo, isso facilita o ingresso no submundo do crime, principalmente no mercado de substâncias tóxicas.

Diante desse quadro, a condição de ser o agente usuário de drogas não exclui a possibilidade de ser condenado como traficante, porque são situações que não se excluem, ainda mais no caso, em que o próprio réu assumiu que a droga era de terceira pessoa e ele estava somente guardando-a, em troca de pagamento em dinheiro.

Reconheço, pois, a ocorrência do delito, e passo a aplicar a pena.

O acusado não ostenta maus antecedentes, no entanto, nesta fase da aplicação da pena, deve ser levado em conta que a introdução da considerável quantidade de droga no mercado (nada menos do que 871,74 gramas de maconha), se fosse alcançada, traria efeitos altamente lesivos à sociedade. Evidente, assim, a necessidade de um maior rigor na fixação da pena-base, em patamar acima do mínimo legal, lembrando que seria absolutamente desprovido de razoabilidade apená-lo com a sanção base mínima, tratando-o igualmente, por exemplo, a quem fosse preso traficando algumas gramas daqueles entorpecentes.

Essa é a posição de nossos Tribunais:

“Na avaliação das circunstâncias legais para a fixação da pena, em se tratando de tráfico de entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade da droga. O tipo de entorpecente é dado que indica o grau de nocividade para a saúde pública, correlato ao indicador das consequências do crime; a quantidade, quase sempre, aponta para o grau de envolvimento do infrator com o odioso comércio, indicando a medida de sua personalidade perigosa e voltada para a prática criminosa” (STJ, HC 13.231-MS, 5ª T., j. 22.08.2000, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 09.10.2000 – RT 786/599).

“Nos casos de tráfico de entorpecente, a fixação da pena obedecerá aos critérios do art. 59 do CP entre eles os motivos, as circunstância e consequências do crime, razão pela qual se admite a fixação de pena-base acima do mínimo legal, se houve apreensão de grande quantidade de droga” (STJ, HC 11.235-SP, 5ª T., j. 16.03.2000, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 17.04.2000, RT 783/594).

“Admissível, em tema de comércio clandestino de entorpecente, é a maior severidade na repreensão penal em face da natureza mais nociva ou da maior quantidade de substância tóxica apreendida” (TACRIM-SP-AC-Rel. Geraldo Pinheiro – JUTACRIM 44/293).

“A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em consequência, a aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública” (TJRS – AC – 687055624 – Rel. Alberto de Moraes Lacerda – RJTJRS 130/154)

PENA – Agravantes – Tráfico de entorpecentes – Associação – Hipótese em que, se a Justiça Pública houvesse apelado, caberia modificação no decreto condenatório, pois a grande quantidade de entorpecente apreendida justificaria plenamente a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, além de que o “modus operandi” do casal criminoso, demonstra organização que merecia maior rigor punitivo; todavia, como não é possível “reformatio in pejus”, a pena cominada na r. sentença deve

prevalecer – Preliminar rejeitada, recurso parcialmente provido. (Apelação Criminal n. 1.044.309-3/5 – São Paulo – 6ª Câmara Criminal – Relator: Marco Antonio – 23.8.2007 – V.U. – Voto n. 6.277)

Portanto, levando em conta o dado elencado, no aspecto acima relatado (quantidade da droga), elevo a pena-base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (fls. 323/324 – Proc. nº 0016904-77.2015.8.26.0032), no entanto, compenso-a com a atenuante da confissão espontânea, permanecendo as penas em seu patamar inicial.

Neste sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao analisar apelação interposta em ação penal que tramitou por este Juízo, decidiu sobre o acerto da referida compensação e a manteve, conforme parte voto que segue:

“... Na segunda fase, a agravante da reincidência (fls. 59/69) e a atenuante da confissão foram compensadas, de modo que as reprimendas permaneceram nos patamares iniciais de quatro anos e oito meses de reclusão e onze dias-multa” (TJSP, Apelação Criminal nº 990.09.282738-3, Comarca de Birigui, 5ª Câmara Criminal, rel. Des. Tristão Ribeiro, j. 25.02.2010, v.u.).

Na terceira fase, não vislumbro a existência de causas de aumento ou diminuição de pena. Neste ponto, não há como se aplicar a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, porque, entre os requisitos legais para tal benefício, o acusado deve ser primário, condição que o réu não ostenta.

Ademais, ainda que o réu fosse primário, a quantidade expressiva de entorpecente, inversamente ao princípio da insignificância, poderia causar consequências gravíssimas a um número imenso de pessoas, bem como denota periculosidade acentuada por parte do acusado, já que realizava o tráfico em escala considerável, o que deve ser diferenciado do pequeno traficante, sob pena de violação do primado da igualdade, de modo que é forçoso reconhecer que se dedicava a atividade criminosa, fazendo do tráfico o seu meio de vida, o que só vem confirmar a não incidência da causa de diminuição supracitada.

Torno definitiva a pena em em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Diante da gravidade da conduta, mesmo levando-se em conta a detração penal disposta na Lei nº 12.736/12 (art. 2º, que acrescentou o § 2º ao art. 387 do CPP), a pena deve ser cumprida no regime inicial fechado, obrigatoriamente, pois se trata de crime equiparado a hediondo, conforme estatuído no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.

Ademais, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária do acusado, isto é, se não registra outras condenações ou prisões processuais, nem quanto ao seu comportamento e conduta no cárcere, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à míngua de informações concretas.

O acusado deverá continuar a responder preso por este processo, pois assim permaneceu durante a instrução e ainda estão presentes os requisitos da custódia cautelar, como se verá doravante.

Fica fixado cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR JEFERSON SANCHES DE SOUZA DA SILVA, qualificado nos autos, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90), e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no menor valor (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06), dando-o como incurso nas penas do

artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Consigno que o acusado ficou preso cautelarmente desde 27/01/2021 até a presente data, período sobre o qual fica reconhecida a detração penal, para fins de cumprimento do restante da pena, nos termos do que dispõe o artigo 1º da Lei nº 12.736/12.

Deve, no entanto, a Serventia, ao expedir a Carta de Guia, atentar para se consignar a condenação total constante do dispositivo acima, com as observações consignadas no parágrafo anterior (detração penal).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender incabível tal providência.

Não obstante o julgamento do Habeas Corpus n. 97.256, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se entendeu por inconstitucional a vedação à substituição por penas restritivas de direitos para o crime de tráfico, por afronta ao princípio da individualização da pena, até então não se trata de decisão proferida com efeito erga omnes.

Foi editada a Resolução nº 5/2012, do Senado Federal, que, nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, suspendeu a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, que vedava de forma abstrata (sem análise do caso concreto) a conversão em penas restritivas de direito, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo em decisão no Habeas Corpus já mencionado acima.

Com a mencionada Resolução, não se pode mais afirmar que o efeito do julgamento daquele habeas corpus não é para todos. Entretanto, a intenção do Supremo Tribunal Federal, ao decidir desta forma, e o Senado Federal, ao editar a resolução, foi somente deixar à prudente análise do magistrado do caso concreto se o réu tem ou não direito a ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, e não que essa substituição seja admitida em qualquer caso de tráfico de drogas, indistintamente. Pensar assim seria um contra-senso.

Confira, neste sentido, decisão proferida em Apelação Criminal que analisou sentença proferida por este juízo:

"... Inviável, nesse passo, a pretendida substituição carcerária por restritivas de direito, porque, embora o teor da recente Resolução nº. 5/2012 do Senado Federal, fundada na decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do Habeas Corpus, nº. 97.256/RS - mencionado nas razões recursais -, em controle difuso de constitucionalidade, in casu, permanece impossível, data vênua, a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, ou mesmo a concessão de sursis, pois o crime de tráfico de entorpecentes revela a gravidade peculiar que desestabiliza a vida em sociedade e fere de morte a saúde pública, pois enquanto fomenta, simultânea e irremediavelmente - até as pedras estão cansadas de saber -, a violência, a destruição de lares e das famílias e a prática de n crimes, sobretudo para o fim de viabilizá-lo, tanto assim que, por força de norma constitucional, é assemelhado aos delitos hediondos, cuja pena deve ser cumprida no regime prisional inicial fechado, determinação esta que se mostra incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou com a suspensão condicional da pena, de modo que não se consegue compreender ou avaliar, por mais que se esforce, qual seria a pena substitutiva ou as condições do sursis adequadas ao traficante, emergindo sintomático que - até o momento - jurista sério algum tenha ousado sugeri-las..." (TJ-SP, Apelação Criminal nº 0009435-15.2010.8.26.0077, 5ª Câmara Criminal, rel. Des. Juvenal Duarte, j. 19.04.2012).

Ainda no mesmo sentido, confira julgamento proferido em processo que tramitou por essa comarca de Birigui:

"Também não faz jus a apelante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados a tráfico de drogas é incompatível com a gravidade e as circunstâncias em que o crime é cometido, não havendo qualquer tipo de violação ao princípio da individualização da pena.

Este entendimento deve prevalecer, notadamente ao se considerar a vedação expressa trazida pelo artigo 44 da Lei de Drogas.

Com efeito, o benefício consistente na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tem por objetivo primordial o de possibilitar a ressocialização de indivíduos de baixa periculosidade, que praticaram delitos de pequeno grau de lesividade social.

Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de pequeno, médio ou grande porte, não tem o perfil de iniciar o cumprimento de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor, as quais virão a repercutir a toda a coletividade. Ressalta-se que uma das exigências previstas no artigo 44, inciso III, do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é a de que os motivos e as circunstâncias indiquem como suficiente tal medida, para a repressão do agente da conduta delituosa.

Conforme já fundamentado, tal benefício não se coaduna com as graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causa, não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental, mas também ao corpo social (deseestrutura familiar, estímulo à prática de outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).

Muito embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do "Habeas Corpus" nº 97256/RS, tenha expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no § 4º, do artigo 33, da Lei 11343/06, é de se ressaltar que tal decisão não possui o erga omnis.

E mesmo a resolução nº 5 do Senado Federal, de 15 de fevereiro de 2012, que suspendeu a eficácia da referida expressão, não acarreta direito subjetivo do agente que praticou o grave delito do tráfico de entorpecentes a tal conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Frise-se, ainda, que o artigo 44 da Lei de Drogas mantém tal vedação ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput. Considerando que o § 4º é tão somente uma causa de diminuição do delito previsto no caput - e não um crime autônomo -, é possível concluir que a vedação a ele também se aplica.

Neste aspecto, ensina Guilherme de Souza Nucci que "(...) o fato de haver sido prevista uma causa de diminuição de pena para o traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações criminosas, não afasta a tipificação da sua conduta como incursas no artigo 33, caput e § 1º, que são consideradas similares a infrações penais hediondas, como se pode observar pelas proibições enumeradas no artigo 44 da Lei 11343/06. Salienta-se, ademais, o cuidado legislativo em vedar a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, típica opção de política criminal para o tráfico ilícito de drogas. Não se pode criar uma nova infração penal, a partir da mera aplicação de causa de diminuição de pena. Por isso, o tráfico ilícito de drogas será sempre considerado equiparado a hediondo, ainda que comporte, por opção legislativa, pena mais branda, quando os requisitos do § 4º estiverem presentes" (in "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas", 5ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p.372).

Desta forma, NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau" (Apelação Criminal nº 0002364-20.2014.8.26.0077. Rel. Toloza Neto).

Não bastassem todos os argumentos expostos nos votos supracitados, no caso concreto, a substituição não é possível, porque a pena aplicada é superior a quatro anos e o réu é reincidente em crime doloso, não preenchendo, pois, os requisitos legais para a substituição. Afora isso, o réu guardava considerável quantidade de entorpecente para entrega a consumo de terceiros, o que demonstra que o benefício não seria recomendável, nem suficiente para a prevenção e repressão do crime praticado.

O acusado deverá continuar a responder preso a este processo, eis que sua prisão preventiva foi decretada às fls. 52/55, a cujos fundamentos me reporto, como razão de decidir, bem como aqueles expostos na decisão de fls. 142/143, que indeferiu

pedido de liberdade provisória.

Por fim, anote-se que o réu guardava grande quantidade de droga, o que traria efeitos altamente lesivos à sociedade e só vem confirmar a necessidade de manutenção de sua prisão cautelar, para garantia da ordem pública, lembrando que o acusado é reincidente em crime doloso.

A confirmar a necessidade da manutenção da prisão cautelar do acusado, estão as decisões proferidas no Habeas Corpus impetrado em favor do acusado, que teve sua liminar indeferida (fls. 163/165), e, ao final, sua ordem denegada (fls. 326/332). Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, com fundamento nos artigos 59 da Lei nº 11.343/06, c.c. o § 4º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, acrescentado pela Lei nº 11.464/07.

Por fim, em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, após 85 (oitenta e cinco) dias contados da publicação da sentença, tornem os autos conclusos para revisão da necessidade de manutenção ou não da decisão que manteve a prisão preventiva, mantendo-se os autos na fila "acompanhamento de prisão preventiva".

A incineração da droga já foi determinada e realizada às fls. 52/55 e 288/289, respectivamente, nada mais havendo a ser decidido a respeito.

Quanto à balança de precisão, diante da natureza do objeto, entendo não ser caso de perda, mas sim destruição imediata, a qual fica desde já determinada, expedindo-se o necessário e comunicando-se a Sala de Armas e Objetos Apreendidos, independentemente do trânsito em julgado da presente.

Oficie-se à Delegacia de Polícia de origem, informando sobre a destruição do objeto (balança de precisão), instruindo-se o ofício com as cópias.

Fixo cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica do réu.

Com o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 28 da Resolução nº 23.399/13 do TSE, instruindo o ofício com cópias da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Custas, na forma da lei.

P. R. I.

Birigui, 01 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA